

1523565-62.2021.8.26.0266

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... razão à acusação na imputação de tráfico que é ofertada ao acusado. É que a quantidade de droga encontrada (143,5g de cocaína e 235,2g de maconha), e as circunstâncias que envolvem o caso (a forma como estavam acondicionados os entorpecentes, e a localidade em que se encontrava, ou seja, conhecido ponto de tráfico), transparecem a finalidade comercial própria do tipo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Foro de Itanhaém

1ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, Itanhaém-SP - cep 11740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1523565-62.2021.8.26.0266 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 07/03/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523565-62.2021.8.26.0266

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLAN OLIVEIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS.

ALLAN OLIVEIRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos delituosos narrados na introitoal de fls. 01/03, a saber:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de novembro de 2021, por volta das 10h40min, na Estrada Cel. Joaquim Branco, nº 1, Savoy, nesta cidade e comarca de Itanhaém, ALLAN OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado à fl. 42, com 18 (dezoito) anos, trazia consigo, para fins de comercialização, 140 (cento e quarenta) microtubos e 225 (duzentos e vinte e cinco) envelopes plásticos contendo cocaína, pesando 226 (duzentas e vinte e seis) gramas, 91 (noventa e uma) porções de cannabis sativa L, pesando 300 (trezentas) gramas, cf. auto de constatação preliminar de fls. 31, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, o denunciado trazia consigo, para fins de venda,

os entorpecentes acima descritos em uma sacola plástica e um radio transmissor (HT). Ao avistar a viatura da polícia militar, que se encontrava em patrulhamento pelas redondezas, o denunciado adentrou no campo de futebol, demonstrando nervosismo. Neste momento, considerando a atitude suspeita do denunciado, os policiais militares foram ao encontro dele, o qual, visando empreender fuga, seguiu em direção à mata existente aos fundos do campo de futebol. Contudo, o denunciado foi alcançado e, realizada abordagem, confessou informalmente que se encontrava trabalhando naquele ponto de tráfico há uma semana. Diante disso, foi preso em flagrante delito.”

Acompanhou a denúncia o auto de prisão em flagrante, no qual, estando em termos, foram juntados, dentre vários outros documentos, termos de declarações, o boletim de ocorrência (fls. 12/14), o auto de constatação preliminar de substância entorpecente apreendida (fl. 34), o auto de exibição e apreensão (fl. 35), a nota de culpa (fl. 46) e o relatório lavrado pela Polícia Judiciária (fls. 82/83). Ulteriormente, foi anexado aos autos o laudo toxicológico (fls. 152/154).

Por ocasião da audiência de custódia (fls. 68/69), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com esteio no art. 312 do Código de Processo Penal, por entendê-la necessária à garantia da ordem pública (fls. 70/73). Mandado de prisão expedido às fls. 74/75 e cumprido às fls. 104/105.

À fl. 99 determinou-se a notificação do acusado para fins de apresentação da defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06. Notificado (fls. 110/111), apresentou-a à fl. 113, por intermédio de seu defensor dativo. Por estar em termos, foi de exordial devidamente recebida, designando-se audiência de instrução e julgamento (fls. 118/120).

Na solenidade, abertos os trabalhos, ressaltou-se que o réu seria interrogado após a inquirição das testemunhas arroladas, seguindo a mesma sistemática do procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo. Na sequência, fora dispensada a inquirição das testemunhas Danilo e Admir, seguindo-se o interrogatório do réu. Então, rumou o feito para os debates orais, em vista da inexistência de diligências complementares. A acusação, em linhas gerais, propugnou pela integral procedência da denúncia, ao passo que a defesa requereu a absolvição do réu, sob a égide da anêmia de provas.

É o breve relato dos autos (artigo 381, incisos I e II, do Código de Processo Penal). FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal manejada pelo Ministério Público com o fito de obter a condenação do acusado Allan Oliveira dos Santos nas sanções do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade da narcotraficância encontra-se sobejamente evidenciada por intermédio do auto de constatação prévia de entorpecente (fl. 34), do auto de exibição e apreensão (fl. 35) e, principalmente, pelo laudo toxicológico de fls. 152/154, oportunidade em que concluíram os experts tratarem-se as substâncias apreendidas de 143,5g de cocaína e 235,2g de maconha. A autoria do acusado, da mesma forma, malgrado o louvável esforço da defesa, ressuma igualmente caracterizada pela prova testemunhal produzida.

Quando de seu interrogatório realizado na fase indiciária (fls. 08/09), alegou ser usuário de drogas, sendo que, na manhã dos fatos, estava indo comprar entorpecentes na biqueira quando policiais militares chegaram. Nesse instante houve uma correria e alguém largou no chão a sacola com as drogas. Afirmou ter sido o único a ser detido porque caiu no chão e os policiais o prenderam, dizendo que as drogas eram suas, o que, todavia, não corresponde à realidade. Em Juízo, na essência, confessou os fatos, nos termos da peça incoativa.

É claro que a confissão do réu, por si só, não é fundamento suficiente para lastrear sua condenação, devendo vir amparada em outros elementos de prova. Vale dizer, conforme art. 197 do Código de Processo Penal,

"o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância."

Pois bem, no caso dos autos, realizado o referido cotejo, revelou-se inarredável coerência entre as palavras do acusado e as demais provas amealhadas.

O policial militar Danilo, em seu depoimento prestado em solo policial (fl. 05), aclarou que às 10h45 no dia dos fatos estava em serviço com o CbPM Admir, realizando patrulhamento de rotina pela Estrada Coronel Joaquim Branco, próximo ao campo de futebol da Av. Cabuçu, quando avistaram um indivíduo que, ao ver a viatura, demonstrou certo nervosismo e entrou no campo, com uma sacola plástica preta em uma das mãos. Pararam a viatura e desembarcaram, momento em que o indivíduo empreendeu fuga em direção à área de mata nos fundos do campo, porém foi acompanhado e detido pelos militares. Asseverou haver realizado busca pessoal do acusado, porém não encontrando nada de ilícito em suas vestes. Todavia, dentro da sacola que estava em poder do inculcado, encontrou um rádio transmissor (HT) pequeno e três sacos plásticos transparentes contendo diversos eppendorfs com substância assemelhada à cocaína, vários envelopes plásticos transparentes fechados à vácuo, também com substâncias assemelhadas à cocaína, e diversas porções de substâncias assemelhadas à maconha. Indagado o deito a respeito, ainda no local, fora por ele dito que iria iniciar seu turno, e já trabalhava naquele ponto de tráfico acerca de uma semana, auferindo entre R\$ 800 e R\$ 1000 por dia. Diante de tais fatos, deu voz de prisão a Alan, o qual foi conduzido à UPA de Itanhaém para exame cautelar e, em seguida, ao plantão.

Estes, em linhas gerais, foram os mesmos fatos articulados pelo policial militar Admir, em seu depoimento prestado em solo policial (fl. 06).

É cediço que o valor do depoimento policial, inexistindo má-fé, constitui importante elemento de prova, o qual merece confiança, pois realizado após compromisso e sem contradita da parte do réu. Aliás, sobre a validade dos depoimentos dos policiais, relembre-se que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

Em outras palavras, segundo os policiais militares, na data dos fatos encontravam-se na Estrada Coronel Joaquim Branco quando se depararam com um indivíduo em atividade suspeita. Ao abordá-lo, lograram encontrar, em poder do abordado, expressiva quantidade de entorpecentes.

Estas são as provas. Diferentemente do que pretende fazer crer a defesa, entendo assistir razão à acusação na imputação de tráfico que é ofertada ao acusado. É que a quantidade de droga encontrada (143,5g de cocaína e 235,2g de maconha), e as

circunstâncias que envolvem o caso (a forma como estavam acondicionados os entorpecentes, e a localidade em que se encontrava, ou seja, conhecido ponto de tráfico), transparecem a finalidade comercial própria do tipo penal.

Observe-se ainda que os entorpecentes apreendidos já se encontravam em pequenas porções, adredemente preparados para venda, e que a abordagem fora realizada após a atitude suspeita esboçada pelo acusado. Veja-se que os depoimentos prestados pelos policiais mostraram-se harmônicos, incluindo neles a confissão do réu na abordagem, sendo, ainda, secundados pela apreensão de entorpecentes.

Todo o contexto da situação flagrancial não deixa dúvidas acerca da conduta ilícita cometida pelo acusado. De resto, não se pode imaginar razões que justifiquem a alegação de estarem os policiais a acusar um desconhecido da prática de um delito, quando isso não ocorreu, unicamente para atender a algum sentimento íntimo sádico de culpar terceiros.

Diga-se de passagem, oportuno lembrar que:

“o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

E ainda:

“considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004).

Em resumo, encontra-se, pois, o acusado incurso nas sanções artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA:

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta do acusado, deve ser considerada normal.

O acusado não é possuidor de antecedentes criminais. E isso porque, não havendo condenação definitiva, tal aspecto não poderá ser valorado em ser desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardando em âmbito constitucional. Vale dizer,

“(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado”(STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09)

Nesse sentido, aliás, é a Súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos são próprios à espécie. As consequências devem ser consideradas normais.

Já as circunstâncias devem ser consideradas gravosas, tendo em vista a vasta quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como sua diversidade e as circunstâncias que envolveram o fato. Pondere-se que a quantidade de entorpecente encontrada, não se dá com qualquer traficante de pequeno porte, evidenciando,

sobremaneira, um maior envolvimento do réu, na prática delitiva em questão. Ainda, vale a consideração que, o montante de droga encontrada na residência do réu, se traduz no mercado ilícito em expressiva cifra, razão pela qual exaspero a pena em 1/6. Neste sentido:

"(...) na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, sem se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade de droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa" (STJ, Rel. José Arnaldo da Fonseca, HC 18940/RJ).

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias judiciais, aplico a pena-base ao réu em seu mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes quaisquer agravantes. Presentes as atenuantes de menoridade, ex vi no inc. I do art. 65 do Código Penal, e da confissão espontânea, ex vi do art. 65, inc. III, d, do CP, atenuo a pena até seu limite mínimo.

Ausentes quaisquer causas de aumento. Presente, por outro lado, a causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. E isso porque, além de se tratar de um direito subjetivo, verifica-se que o acusado é primário, portador de bons antecedentes. Embora efetivamente responda o acusado por outros feitos, o Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. Assim, o mesmo raciocínio deve balizar a análise da aplicação do redutor em questão.

Portanto, fica então operada a diminuição em 1/6, dada à diversidade e nocividade da droga. A este respeito, observo que:

"o artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do artigo 33 da nova Lei de Drogas" (STJ; HC 163495/SP; Rel. Min. Laurita Vaz; DJe 19/10/2011).

Inexistindo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, em 04 (quatro) anos e 02 meses de reclusão.

Considerando que Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), deve o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, não podendo fundamentar a fixação do regime inicialmente fechado unicamente em relação à hediondez do delito de tráfico de drogas.

A tese restou assim ementada:

"É inconstitucional a fixação ex lege, com base no artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal." (ARE 935.967 AgR; Rel. Min. Edson Fachin; Primeira Turma; J.:15.03.2016)

Desse modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. Vale ressaltar que tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do §3º do art. 33, c.c art. 59 do Código Penal.

Na espécie, a pena privativa de liberdade, a despeito da primariedade do réu, deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, dada à diversidade e nocividade da droga.

A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito há de ser analisada sob o prisma do artigo 44 do Código Penal.

Conquanto expressa a vedação acerca da aplicação do instituto aos casos de tráfico, tal qual se depreende dos arts. 33, §4º, e artigo 44, ambos da Lei n. 11.343/06, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Habeas Corpus n. 97256, publicado em 16/12/2010, cujo relator foi o Min. Ayres Brito, em controle difuso de constitucionalidade, concedeu a segurança pretendida para:

“remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos', constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.” E isso por se entender que “o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material”.

Ademais, em 15/02/2012, o Senado Federal, valendo-se da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 52, inc. X, da Constituição Federal, editou a Resolução n. 5, suspendendo a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do §4º do art. 33, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Ainda que a Resolução editada pelo Senado Federal tenha se limitado a suspender a restrição existente somente no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, forçosa é a extensão de sua leitura também para a redação dada ao art. 44 do mesmo diploma, quando veda o mesmo benefício. É que o precedente jurisprudencial que motivou a edição da Resolução referida entendeu por inconstitucional tanto a vedação contida no art. §4º do art. 33 como também a do art. 44, ambos da Lei n. 11.343/06.

Todavia, mesmo que assentadas tais premissas, as circunstâncias do caso indicam não ser recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou, ainda, a suspensão condicional de sua execução. Como já positivado, foram encontradas mais de uma espécie de entorpecente, o que revela nocividade em seu comportamento, não compatível com a branda possibilidade de concessão dos benefícios referidos (artigo 44, inciso III, e artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal).

Face à substituição da pena privativa de liberdade, incabível se mostra a suspensão

de sua execução (art. 77, inc. III, do CP).

DIANTE DO EXPOSTO:

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado ALLAN OLIVEIRA DOS SANTOS, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicialmente semiaberto. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c §4º do mesmo dispositivo, ambos da Lei n. 11.343/06.

Deixo de condenar o réu em custas processuais, dada hipossuficiência denotada.

Por estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ante os fundamentos elencados na decisão de fls. 68/69, não reconheço ao acusado o direito de recorrer em liberdade, recomendando-se-o no ergástulo em que se encontra até o trânsito em julgado (artigo 387, §1º, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal).

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa das vítimas.

Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da tabela do convênio OAB – Defensoria ao(s) procurador(es) nomeado(s). Expeça-se certidão com o trânsito em julgado.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

1. Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
2. Lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal;
3. Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se ao Juízo da Execução, conforme artigo 105 da 7.210/84.

Registre-se. Cumpra-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Itanhaém, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA